

0002452-06.2017.8.26.0028

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... que confirmado em juízo.

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO.

NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

2ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, . - São Roque

CEP: 12570-000 - Aparecida - SP

Telefone: (12) 3105-3352 - E-mail: aparecida2@tjsp.jus.br

0002452-06.2017.8.26.0028 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0002452-06.2017.8.26.0028

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adriano Alves Cardoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia ADRIANO ALVES CARDOSO, como incurso na prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

ADRIANO ALVES CARDOSO, já qualificado nos autos, foi denunciado e viu-se processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 30 de abril de 2017, por volta das 12h00min, na Rua Chicó Santeiro, Jardim Paraíba, nesta urbe, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, contra Neide Aparecida da Rocha e Roberto Bueno da Silva, uma bolsa da marca VICTOR HUGO que continha cartões bancários e documentos pessoais, 2 pares brincos de ouro e um celular LG, avaliados indiretamente no importe de R\$3.210,00, além da quantia de R\$12.00, em espécie, pertencentes a Neide Aparecida da Rocha.

De acordo com a narrativa fática trazida na denúncia, apurou-se que, as vítimas caminhavam pela via supramencionada, ocasião em que foram abordadas pelo indiciado, o qual lhes exibindo uma arma de fogo, anunciou o assalto, vindo a apoderar-se da bolsa de Neide.

Ato contínuo, a vítima Roberto atracou-se com ADRIANO, ocasião em que este disse: "me larga senão eu dou um tiro". Em face de referida ameaça, a vítima soltou o roa denunciado, que fugiu em sua bicicleta na posse da bolsa subtraída.

Oportuno salientar que, posteriormente, as vítimas efetuaram o reconhecimento fotográfico de ADRIANO, consoante autos de reconhecimento fotográfico.

Denúncia recebida em 24 de abril de 2018 (fls. 97/98).

Citado, o acusado ofereceu Defesa Prévia às fls. 138/149, pleiteando pela absolvição sumária e pela rejeição da denúncia.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as vítimas, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e as testemunhas arroladas pela Defesa. Por fim, interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público pediu a procedência da denúncia nos exatos termos em que formulada, por estar devidamente comprovada autoria e materialidade delitiva.

A Defesa, por sua vez, em seus memoriais finais, sustentou, em sede de preliminar, a nulidade da prova obtida a partir de reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades legais. Pediu, ainda em sede de preliminar, o reconhecimento da nulidade de todo o inquérito policiais, em razão da teoria dos frutos da árvore envenenada, uma vez que, com a nulidade da prova, toda a persecução penal dela oriunda se encontra eivada de nulidade. No mérito, sustentou a ausência de prova da autoria delitiva, impondo-se, assim, a absolvição do réu. Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

PRELIMINARES

NULIDADE DA PROVA E DA AÇÃO PENAL CORRELATA

A combativa defesa sustenta que, em razão do reconhecimento realizado em solo policial não ter observado as formalidades estabelecidas na legislação processual penal, tal procedimento é nulo e macula todo o inquérito policial e, via de consequência, a ação penal.

Nesse ponto, não assiste razão à defesa.

Primeiramente, cumpre salientar que o inquérito policial é um procedimento administrativo inquisitório e preparatório, presidido pela autoridade policial, consistente em um conjunto de diligências realizadas pela polícia investigativa objetivando a identificação das fontes de prova e a colheita de elementos de informação quanto à autoria e materialidade da infração penal, a fim de possibilitar que o titular da ação penal possa ingressar em juízo.

Trata-se de um procedimento de natureza instrumental, porquanto se destina a esclarecer os fatos delituosos relatados na notícia de crimes, fornecendo subsídios para o prosseguimento ou o arquivamento da persecução penal.

Logo, como o inquérito policial é mera peça informativa, eventuais vícios dele constantes não têm o condão de contaminar o processo penal a que der origem.

Havendo, assim, eventual irregularidade em ato praticado no curso do inquérito, mostra-se inviável a anulação do processo penal subsequente.

Ao longo do inquérito policial são obtidos elementos de informação que irão subsidiar o titular da ação penal, neste caso, o Ministério Público, a formar sua opinio delicti.

Elementos de informação são aqueles colhidos na fase investigatória, sem a obrigatória observância do contraditório e da ampla defesa.

Salienta-se, ainda, que os elementos de informação não podem, de forma isolada, embasar um decreto condenatório.

Tendo em conta que esses elementos de informação não são colhidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa, deduz-se que o inquérito policial tem valor probatório relativo.

Como já se manifestou o STF, os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios que passam pelo crivo do contraditório em juízo.

Portanto, analisando as teses processuais levantadas pela defesa, observa-se que eventual irregularidade na obtenção de tais elementos de informação, não tem o condão de macular o andamento da ação penal respectiva.

Assim, eventuais irregularidade não contaminam o andamento da ação penal, devendo a qualidade e profundidade dos elementos de informação serem analisando em conjunto com as demais provas obtidas, matéria essa afeta ao mérito da ação penal.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 34, XX, E 202 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO. DEPOIMENTO E DOCUMENTOS FORNECIDOS NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. NÃO VERIFICADA. DENÚNCIA LASTREADA EM ELEMENTOS AUTÔNOMOS. PRINCÍPIO DA AQUISIÇÃO PROCESSUAL OU DA COMUNHÃO DA PROVA. INQUÉRITO POLICIAL. NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. VÍCIOS QUE NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017).

II - Os artigos 34, inciso XX, e 202, ambos do RISTJ, atribuem ao Relator a competência para "decidir o habeas corpus quando for inadmissível, prejudicado ou quando a decisão impugnada se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar".

III - A interposição do agravo regimental torna superada a alegação de afronta aos princípios do juiz natural e da colegialidade e torna prejudicados eventuais vícios relacionados ao julgamento monocrático, tendo em vista que, com o agravo, devolve-se ao órgão colegiado competente a apreciação do mérito da ação, do recurso ou do incidente.

IV - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

V - In casu, sustenta-se a nulidade da Ação Penal n.

5030173-60.2016.4.04.7000/PR, com base no argumento de que todos os elementos de informação nos quais se lastreou a peça acusatória teriam sido obtidos em violação ao princípio da não auto-incriminação, visto que teriam sido fornecidos exclusivamente pela recorrente na condição de testemunha, compromissada a dizer a verdade e sem que lhe fosse garantido o direito de permanecer em silêncio, embora a autoridade policial e o Ministério Público Federal, em tese, por ocasião da oitiva, já tivessem convicção formada quanto à sua participação em fatos investigados na Operação Lava Jato.

VI - Em juízo de cognição sumária, próprio ao habeas corpus, verifica-se que a formulação da opinio delicti do órgão acusatório e as decisões das instâncias precedentes fundamentaram-se em elementos independentes das declarações e do material apresentado pela recorrente no curso do inquérito policial. Ao contrário, nota-se que o depoimento e os documentos por ela apresentados na etapa inquisitória encerraram importância apenas secundária ou acessória na fundamentação da decisão que admitiu a peça acusatória.

VII - De acordo com o princípio da aquisição processual ou da comunhão da prova, as provas com que a parte instrui os autos - aí incluídos os documentos - passam a pertencer ao processo e, nessa medida, podem ser empregadas para a persuasão racional do magistrado independentemente de quem a tenha produzido. Desse modo, a fundamentação das decisões das instâncias ordinárias com base em documentos

fornecidos pela recorrente em sede de contrarrazões apresentadas em recurso em sentido estrito não pode ser interpretado como violação ao princípio da não auto-incriminação.

VIII - Eventual nulidade na oitiva da recorrente no curso da investigação preliminar não tem o condão de nulificar o recebimento da denúncia e a ação penal deflagrada, tendo em vista que, por um lado, existem elementos autônomos que sustentam as decisões impugnadas; e, por outro, eventuais vícios na fase extrajudicial não contaminam o processo penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 124.024/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020) (grifo nosso)

Portanto, rejeito a preliminar levantada.

No mais, o feito encontra-se em ordem. Não há outras preliminares a dirimir.

Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais.

Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

No mérito, a ação penal é IMPROCEDENTE.

Com efeito, analisando atentamente o acervo probatório, e considerando os elementos indiciários existentes nos autos, verifica-se não haver prova suficiente para embasar um decreto condenatório, devendo ser o acusado ser absolvido dos delitos imputados.

A materialidade delitiva resultou provada pelo Boletim de Ocorrência alusivo aos fatos (fls. 07/09), Termo de Declarações de Neide Aparecida da Rocha (fls. 10, 12/13, 43), Ordem de Serviço (fls. 11), Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 14/15, 18/19, 66, 67), Termo de Declarações de Roberto Bueno da Silva (fls. 16/17), Relatório do Setor de Investigações (fls. 20/21). Fotografias (fls. 36/37, 55), Relatório Final oferecido pelo Delegado de Polícia (fls. 87/88), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, todavia, não restou suficientemente demonstrada.

Antes de analisar a prova oral colhida nos autos, cumpre tecer algumas considerações a respeito do reconhecimento fotográfico realizado em solo policial.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça colocou um fim ao entendimento de que as formalidades exigidas pelo art. 226, do CPP são apenas meras sugestões procedimentais.

O reconhecimento do suspeito de um crime por mera exibição de fotografias há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

O art. 226 do CPP admite o reconhecimento de pessoa e impõe o seguinte procedimento para sua validade:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Relator, o ministro Rogerio Schietti destacou que essas formalidades são essenciais para o processo.

O Superior Tribunal de Justiça então fixou as seguintes diretrizes:

1. O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime

2. À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento

da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo

3. Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento

4. O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s), ao reconhecer, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO.

NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. 5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças. 6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua insita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II). 7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não

seguir minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado. 8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias). 9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado 10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado. 11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância). 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. STJ HC 598.886/SC. 6ª TURMA. REL. MIN. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. JULGADO EM 27/10/2020.

A técnica do mug shot ou foto de fichamento na delegacia, por sua vez, consiste na fotografia tirada do acusado no momento de sua prisão e, se mostradas a vítimas e testemunhas podem ter grande influência no reconhecimento devido à crença de que um indivíduo com um histórico de prisão terá mais chances de reincidir. Sobre o tema, Aury Lopes Jr. alerta, ainda, para o fato de que: “Não há dúvida de que o reconhecimento por fotografia (ou mesmo quando a mídia noticia os famosos “retratos falados” do suspeito) contamina e compromete a memória, de modo que essa ocorrência passada acaba por comprometer o futuro (o reconhecimento pessoal), havendo uma indução em erro.” (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 14a ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 495.)

“É que o reconhecimento fotográfico torna vulnerável a formalidade prevista no artigo mencionado diante da substituição da comparação física pela comparação fotográfica, sendo considerado uma prova irritual por não seguir o procedimento.

Igualmente, através da fotografia perde-se a amplitude favorecida pelo reconhecimento pessoal, pois há limitação quanto a identificação das características do indivíduo, bem como a imagem poderá estar desatualizada ou em preto e branco, dificultando a credibilidade.” (GOMES FILHO, A. M.; BADARÓ, G. H. R. I. Prova e Sucedâneos de Prova no Processo Penal Brasileiro. vol. 65/2007. p. 175-208. Revista Brasileira de Ciências Criminais, [S. l.], v. 65, 2007. Artigo consultado na Base de Dados RT Online mediante assinatura. Em pdf, p.1-22.)

“Outrossim, sob o ponto de vista prático, o reconhecimento fotográfico é normalmente adotado em Delegacias de Polícia pelo agente encarregado pela investigação. Nesta oportunidade, é exibido para o reconhecedor um álbum de fotografias – costumeiramente salvo no computador – no qual aparecem diversos indivíduos que foram apreendidos ou detidos anteriormente, cuja finalidade é propiciar que o reconhecedor aponte se algum dos indivíduos é o suposto autor do delito praticado contra si.

Há casos em que a autoridade policial apresenta o álbum de fotografias, antes da realização do reconhecimento pessoal ao reconhecedor, gerando um comprometimento da memória em virtude de um pré-juízo criado e, conseqüentemente, uma indução em erro para a realização do ato . A amostragem de fotografias cria uma memória fotográfica que pode acarretar danos irreversíveis, pois dificilmente a parte terá uma percepção diferente da visualizada e relatada.” (LOPES JR, A. Direito processual penal. 16. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 494-495.)

Em brilhante trabalho realizada por Clarice Lessa de Fraga foi tecida alguns comentários a respeito das falsas memórias e o procedimento do reconhecimento fotográfico:

“O cérebro humano não armazena nenhuma imagem em forma de fotografia de qualquer coisa que tenhamos visualizado ou presenciado, como por exemplo, pessoas ou objetos. Explica-se isso em razão do problema que enfrentaríamos pela falta de espaço na memória, tendo em vista que as pessoas recebem diversas informações ao longo da vida, não sendo possível armazená-las integralmente.

Diante disso, sabe-se que a realização do reconhecimento fotográfico através da amostragem de fotografias gera uma memória fotográfica no reconhecedor, pela qual haverá um confronto entre as lembranças do ato e as imagens apresentadas, sendo que dificilmente haverá um convencimento contrário da parte em razão da contaminação originada pelo efeito da indução Isto ocorre porque a vítima/testemunha realiza o ato probatório com a convicção de que as autoridades somente lhe apresentam as fotografias por haver certeza de que o autor do delito está em alguma daquelas imagens. Todavia, não é o que ocorre na prática, porque a parte procura não frustrar a expectativa criada pela autoridade responsável, vindo a indicar aleatoriamente a imagem que 'mais' se aproxima das características do indivíduo. Por outra banda, através do reconhecimento fotográfico tem-se outro efeito deletério na memória, que é a redução da percepção de características que seriam detectadas caso o ato fosse realizado pessoalmente, considerando que o reconhecedor estará adstrito aos elementos constantes na imagem. Desta forma, resta prejudicada a identificação de características específicas do acusado, pois há casos em que a imagem é somente de rosto, por exemplo, não sendo possível averiguar a altura, o porte físico, alguma expressão etc. Igualmente, salienta-se que através das fotos se tem uma representação estática, pela qual não há demonstração atual e integral das características do indivíduo a ser reconhecido. Por tais razões, no ato do reconhecimento será constatada as circunstâncias percebidas quando retirada a fotografia e não consoante o momento delituoso.

Conquanto, conforme referido anteriormente, as lembranças são o resultado de uma percepção passada, presente e futura. Deste modo, somente será possível a identificação do transgressor através de fotografias se a parte o conhecer, isto é, se a imagem do indivíduo estiver armazenada em sua memória. Caso contrário, quando da realização do reconhecimento pessoal, se houver, a imagem recordada será a apontada nas fotografias e não especificamente do rosto do autor do delito.

Ademais, importante destacar, como visto, que há diversos fatores que corroboram à sugestibilidade e à indicação errônea, como: a seleção de fotos de pessoas que não possuem características físicas semelhantes; a falta de simetria nos formatos

das fotografias; a 'pressão' para que o reconhecedor aponte uma imagem; a convicção do reconhecedor acerca da autoria, porém, trata-se de falsas informações; a indicação de que os indivíduos apresentados são autores de crimes específicos cometidos em determinada localidade e de tal forma; entre outros.

Por tais motivos, o reconhecimento fotográfico não deve servir como único fundamento numa sentença condenatória, pois se trata de um ato fragilizado, que não segue um procedimento legal, e que depende exclusivamente da memória da parte, que poderá apresentar distorções naturais e/ou manipuladas. Além disso, não se deve olvidar que, por estar adstrito a uma imagem que reduz as características físicas do reconhecido, este meio de prova é ainda mais deficitário, motivo pelo qual se defende a necessidade de se provocar a atuação do Legislador de modo a estabelecer uma disciplina legislativa específica para esta modalidade de meio de prova a fim de que se estabeleça uma forma que reduza o número de erros e induções."

(A INFLUÊNCIA DAS FALSAS MEMÓRIAS NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CLARISSE LESSA DE FRAGA. Disponível em [clarice_fraga.pdf](#) (pucrs.br) - acesso em 16/09/2021)

Feitas essas considerações, cumpre ainda salientar algumas circunstâncias que enfraquecem ainda mais o arcabouço probatório e o ato de reconhecimento em si. Quando da lavratura do boletim de ocorrência, a vítima Neide afirmou que: "foi abordado por um rapaz magro, alto, branco e aparentando cerca de vinte anos de idade."

O acusado possuía, à época dos fatos, 41 anos de idade.

Ora, trata-se de substancial diferença de idade. É muito pouco crível que se possa confundir uma pessoa de 20 anos com uma de 41 anos de idade.

Além disso, a vítima Roberto, quando do reconhecimento fotográfico esclareceu que o acusado "estava usando no momento do crime uma blusa de moletom azul claro com capuz, bermuda clara e listrada, visto que utilizou o capuz desta blusa no momento do crime, entretanto não tampou sua fisionomia"

Ainda que a segunda vítima tenha dito que o capuz não tampou (sic) a fisionomia do autor do fato, é certo que tal circunstância dificulta a precisão da identificação e obtenção de maiores elementos a respeito das características físicas do autor do fato.

É certo ainda que não foram produzidos nenhum outro elemento de prova a respeito da autoria do réu, com ele não foi apreendido nenhum dos pertences subtraídos, o fato não foi presenciado por nenhuma outra testemunha.

Assim, a única prova contra o réu é o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, com seus amplos problemas e vícios acima citados.

É certo que uma condenação criminal somente pode ocorrer quando apoiada em provas seguras, cabais e extreme de dúvidas, sendo que indícios isolados ou meras presunções, isoladamente consideradas, não constituem prova dotada dessas qualidades, sendo insuficientes para amparar um decreto condenatório. Ademais, os indícios que autorizam um juízo condenatório são apenas os concludentes e que conduzam a certeza e afastem qualquer hipótese favorável ao acusado (RT 218:96, RT 166:553). Isto porque o Direito Penal não opera conjecturas ou presunções, exigindo prova segura e induvidosa da autoria delitiva. Feitas tais considerações, no caso, verifica-se que apesar de provada a materialidade delitiva, permanece dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

Neste contexto, torna-se temerário considerar como elemento de prova o isolado reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, mormente quando não ratificado, pessoalmente, no contraditório judicial.

Indiscutivelmente, o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial foi claramente irregular e não obedeceu às mínimas formalidades legais. Importante frisar, neste ponto, que, por fatores de ordem técnica, os traços fisionômicos são facilmente alteráveis através de fotografias. Desta forma, ainda que admissível como meio de prova, este deve ser visto com extrema ressalva, não podendo ser aceito, máxime quando isolado e, sobretudo, quando não se sabe se a fotografia foi mostrada diretamente ou selecionada espontaneamente pela vítima em álbum fotográfico. Por tais motivos, o reconhecimento fotográfico tem, lamentavelmente, propiciado os mais lamentáveis enganos, levando à prisão, muitas vezes, pessoas que, posteriormente, se vieram reconhecer totalmente inocentes (RT, 165/565). Sobre

o tema, a preciosa lição contida no julgado do extinto TACRIM, de relatoria de ALBERTO SILVA FRANCO, nos autos da Apelação nº 126.084: "Reconhecimento fotográfico. Embora inquestionável o reconhecimento fotográfico como meio de prova, existe risco neste procedimento, porque não se pode desprezar o fenômeno psicológico da 'atenção expectante' que age como poderosa auto-sugestão a influenciar o reconhecedor. Assim, para se preservar o valor probante do ato, aquele deve previamente efetuar uma descrição dos traços fisionômicos e dos aspectos fisionômicos, retidos em sua memória, da pessoa a ser reconhecida". Por outro lado, não havendo reconhecimento pessoal em juízo, inviável amparar um decreto condenatório com base nos elementos colhidos em sede inquisitorial. Diante disso, sendo frágil, conflitante e contraditório o quadro probatório, inadmissível se mostra o decreto condenatório, tornando imperiosa a absolvição do acusado, vigorando na hipótese o princípio "in dubio pro reo".

Fixadas tais premissas, passo ao exame da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Em juízo, a vítima Neide Aparecida da Rocha, em síntese, afirmou que: (relato livre)

Ele parou pedindo informação. Comecei a dar explicação a ele. De repente ele tirou uma arma, não sabe se é de verdade. Anunciou o assalto. O Roberto segurou nele. Começou a puxar o Roberto. Ela conseguiu soltar o Roberto. Quando ela o viu já estava no final da rua em poder de sua bolsa. Era um cano largo, na manga. Não se recorda dele ter feito ameaça. Ele parou pedindo informação e de repente ele disse que era mentira e era um assalto. Ele puxou da manga um cano com a mão na gatilho. Ela ficou muito assustada. Era meio-dia. O Roberto não se intimidou e segurou nele. Ela puxou o Roberto para trás. Conseguiu tirar o Roberto de cima do acusado, e quando ele a viu estava no final da rua com sua bolsa. Não recuperou seus pertences. Ele estava de bermuda, era um casaco vermelho. Estava com o capuz. Ela olhou a foto e o reconheceu. O que chamou sua atenção foi o casaco com capuz. Ele tinha bastante cabelo. Somente o reconheceu por foto na delegacia. Não o viu pessoalmente.

Do mesmo modo, em audiência, foi ouvida a outra vítima Roberto Bueno da Silva, declarou que: (relato livre)

Estavam andando, ele veio pedir a informação. Ele anunciou o assunto. Ele segurou no braço dele. Ele estava de moletom. Só apareceu o caninho da arma. Ele falou larga se não ele tirar. Ele soltou e ele correu. Ainda tentou correr atrás dele, mas não conseguiu. Faz 4 anos, não lembra muito bem. Só se lembra do moletom ou bermuda. Era uma pessoa bem mais jovem. Bem jovem.

Por fim, em juízo, o réu ADRIANO ALVES CARDOSO, em síntese, alegou que:

São falsos. Negou todos os fatos. Estava em casa nesse dia. Estava de saidinho. Estava em casa. Não conhecia as vítimas. Conhece os policiais que participaram da ocorrência. Foram os mesmos policiais que o prenderam da última vez.

Os depoimentos prestados pelas vítimas, mais uma vez, colocam uma dúvida sobre a veracidade do reconhecimento realizado em solo policial.

Isto porque, a vítima Roberta sustentou que o roubador era "jovem, bem jovem", ao passo que o acusado possuía, a época dos fatos, 41 anos de idade.

No presente caso, esgotada a colheita probatória, tenho que a autoria delitiva não restou suficientemente demonstrada.

Em que pese eventual gravidade dos fatos imputados, isto não é razão suficiente para assumir o risco do erro judiciário em que consistiria a condenação no presente caso, pois o conjunto probatório é demasiadamente frágil. Nisto consiste o mandamento de otimização contido no princípio do in dubio pro reo.

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para ABSOLVER, na forma do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, o acusado ADRIANO ALVES CARDOSO da imputação do cometimento de crime descrito na denúncia art. 157, §2º, I, do CP.

Comunique(m)-se ao(s) ofendido(s) a presente sentença, na forma do art. 201, § 2º do Código de Processo Penal.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Oportunamente, elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Aparecida, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA